

1500393-93.2022.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/10/2022
... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500393-93.2022.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096471/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 24164603 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2096471 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WENDEL RAFAEL APARECIDO DORTA ATANAZIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

WENDEL RAFAEL APARECIDO DORTA ATANAZIO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 07 de Abril de 2022 às 15h45min, na Rua Expedicionário Demerval Oliveira Leme, nº 57, Bairro do Toró, Bragança Paulista - SP, trazia consigo e mantinha em depósito em sua residência para venda ou entrega de qualquer forma a consumo a terceiros, nas proximidades da paróquia São Lázaro da Betânia (conforme fls.65/67), o total de doze porções de maconha (18,0 gramas) droga/entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro.

Devidamente notificado (fl. 83), o acusado apresentou defesa preliminar a fls. 87/90. Recebida a denúncia aos 27 de maio de 2022 (fls. 99/100), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas comuns, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 113).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação postulou a procedência da ação, nos termos da denúncia certa de que as provas colhidas estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 136/140). A defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 143/178).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração.

Muito embora Wendel tenha admitido a propriedade da droga apreendida, negou sua intenção de comercializá-la, argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal. Aduziu, ainda, que o dinheiro localizado em seu poder seria para comprar fraldas para a filha.

Sua escusa não convenceu e restou isolada.

Frise-se, inicialmente, que durante a diligência policial foi apreendida uma razoável quantidade de droga, aproximadamente 12 porções de maconha, além de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro.

Pontue-se, também, que o acusado foi investigado por policiais civis após o recebimento de denúncia anônima que apontava a execução do comércio ilícito de drogas em ponto de traficância próximo da sua residência.

Lado outro, não se apanha usuários com essa quantidade de entorpecente, ainda que próximo a sua residência. Portanto, as circunstâncias de sua prisão se afastam completamente da conduta de mero usuário que apenas possuiria pequenas quantidade para uso próprio.

Destarte, a circunstância de encontrar-se o acusado na posse dessa quantidade de maconha, configura, por si só, a plena demonstração do animus de traficar, mesmo

porque, nenhuma prova segura existe nos autos que demonstre a exclusiva finalidade para uso próprio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno traficante, não se pode cogitar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da fixação de regime inicial diverso do fechado. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém, sem repercussão na pena final. (TJSP; Apelação 0002855-33.2017.8.26.0526; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. Absolvição por falta de provas para o crime de tráfico – inoportunidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas – apreensão de variedade e expressiva quantidade de drogas na residência do recorrente, bem como a arma de fogo – circunstâncias da prisão do recorrente que atestam a prática de tráfico. Penas aplicadas de forma motivada, dentro dos parâmetros legais. Regime fechado é o correto diante da gravidade concreta dos crimes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0001123-48.2017.8.26.0548; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

No mais, ele se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento nesses elementos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução. Senão vejamos.

A testemunha Pedro Henrique, policial civil, declarou que durante investigações visando a repressão do crime de tráfico, a autoridade policial representou pela concessão de uma busca e apreensão domiciliar na residência do acusado. Narrou que, em conjunto com seu colega de trabalho Anderson, foram ao local ocupando uma viatura descaracterizada. Ao perceber a chegada da polícia, o acusado empreendeu fuga, porém foi abordado logo em seguida. Realizada a revista pessoal, localizou-se em poder do acusado uma porção de maconha e R\$ 150,00, em notas trocadas. Informou que para auxiliar nas buscas na residência solicitou-se apoio da Guarda Municipal, quando então o cão farejador da Guarda Civil Municipal encontrou um saco plástico com os demais entorpecentes.

A testemunha Anderson, policial civil, em síntese, corroborou quanto narrado por seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que 15 minutos antes da abordagem já tinha visto e fotografado o acusado realizando atos de mercancia ilícita.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Em que pese o quanto alegado pela defesa, desnecessária apreensão de petrechos e cadernos de contabilidade para a configuração do crime de previsto no art. 33 da Lei de Drogas, bastando a execução de quaisquer atos típicos do referido artigo, tal qual atos de mercancia e posse como narrado nos autos. As fotografias acostadas a fls. 91/94 comprovam que as porções são idênticas. Ademais, caberia à defesa arrolar como testemunha qualquer uma das pessoas que vivem no imóvel, providência não realizada pelo causídico.

Nessa toada, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado e do Município, que auxiliam na repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local, a abordagem policial e revista no imóvel, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENHIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014)

Por outro lado, o acusado sequer indicou testemunha de defesa.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, em porções prontas para a venda, o local e as circunstâncias da apreensão, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

Aduza-se, ainda, que no relatório exarado pela Autoridade Policial, utilizado para o embasamento do pedido de busca domiciliar, verifica-se que o Setor de Investigação recebeu informação de que a pessoa do acusado estaria armazenando em sua residência entorpecentes para posterior comercialização no próprio bairro. Descreveu, ainda, que ao tomar conhecimento da situação, policiais civis realizaram monitoramento da casa e constataram grande circulação de pessoas próximas ao imóvel, movimentação essa típica de locais de comercialização de drogas (fl. 03 - apenso).

A delação também deve ser levada em consideração porque jamais os policiais encontrariam a droga e investigariam a situação de traficância se não possuíssem informação confiável.

As denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas as delações com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "guardar", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Comprovada, ainda, a qualificadora prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto

o laudo fls. 69/71 que atestou que a traficância foi realizada a aproximadamente 115m da Paróquia São Lázaro de Betânia.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Inadmissível o pedido de desclassificação do delito imputado quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa e não da acusação o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser usuário e dependente, mesmo porque a condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário de droga.

Sobre a matéria:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha e possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, calibre 22, uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00008425720168260474 SP 0000842-57.2016.8.26.0474, Relator: Alcides MalossiJunior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio, ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional para o início de cumprimento de pena e detração penal. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado colocar algo em sua boca em atitude suspeita, justificando sua abordagem. Realizada busca pessoal, RENAN cuspiu do interior de sua boca oito pedras de crack envoltas em papel alumínio. Ato contínuo, dando continuidade à busca, os milicianos encontraram em poder do acusado, mais especificamente no interior de suas vestes íntimas, trinta e quatro porções de maconha, todas acondicionadas separadamente em sacos plásticos. Ainda, no interior dos bolsos da bermuda que o denunciado vestia, os policiais apreenderam um celular Motorola e a quantia de R\$ 68,00 em espécie. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente específico que justifica o aumento adequado e proporcional aplicado pelo duto sentenciante, na segunda etapa da dosimetria da pena. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente a reincidência para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. 3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com

redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal. 4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00005459420188260566 SP 0000545-94.2018.8.26.0566, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma nos autos. Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes criminais não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, pois muito embora presente a menoridade relativa do agente, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução neste momento.

Na etapa derradeira, deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III, uma vez que a prova é segura no sentido de que a infração foi praticada a 100 metros de uma entidade religiosa, conforme certificado no laudo anexo (fls. 69/71).

Logo, há proximidade entre os locais, verificando-se a influência e o potencial perigo que o comércio ilícito pode acarretar. Ressalte-se que para o reconhecimento da majorante não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente de fato atinja, diretamente, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., os frequentadores do local, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.

Pretende a lei proteger tais locais, frequentados por grande quantidade de pessoas, algumas delas, em condições especiais. Portanto, o perigo à saúde pública é maior nestes locais, não exigindo a lei que o estabelecimento seja especialmente visado pelo agente.

Nesse sentido:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

"A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local (STJ. 6ª Turma. AgRg no Resp. 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017 STJ; 6ª Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016).

Assim, suas penas serão acrescidas em 1/6 (5 anos + 1/6 = 5 anos e 10 meses /500 dias + 1/6 = 583 dias-multa).

Anote-se que embora o acusado seja primário, constata-se que enquanto adolescente ele respondeu a diversos procedimentos por ato infracional (fls. 41/42). Destarte, ainda que não seja possível sopesar os atos infracionais para considerar o acusado reincidente ou portador de maus antecedentes, conforme entendimento reiterado do STJ, eles podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos previstos no § 4º, qual seja, não se dedicar às atividades criminosas. Eis a Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.022 - MG (2017/0284174-3) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE : IGOR WASHINGTON SOUZA DA SILVA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUESTÕES PREJUDICADAS. Recurso especial desprovido. DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto por Igor Washington Souza da Silva, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0024.15.093125-1/001 (fls. 287/297): APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 INVIABILIDADE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA BENEFÍCIOS NÃO RECOMENDÁVEIS ISENÇÃO DAS CUSTAS IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, é impossível a absolvição. Não é possível aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 se o acusado não preencher todos os requisitos, que são: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa. A quantidade do entorpecente apreendido e a dedicação do acusado a atividades criminosas relacionadas ao tráfico revelam a maior reprovabilidade da conduta do condenado e demonstra não ser suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime em questão a fixação de regime prisional diverso do fechado. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 04 anos (art. 44 do CP). O recurso especial aponta a violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; porque negada a aplicação da causa de diminuição de pena com suporte na prática de atos infracionais. Pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial para que seja aplicada a referida minorante; de forma subsidiária, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Oferecidas contrarrazões (fls. 316/318), foi admitido o recurso na origem (fls. 320/321). O Ministério Público Federal opina pelo não provimento da insurgência (fls. 332/334). RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA, PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, NEGADA, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório Quanto ao pedido de aplicação da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, extrai-se os

seguintes fundamentos do combatido aresto (fls. 294/295 grifo nosso): [...] Razão também não assiste à defesa em requerer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo determina o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para que o condenado faça jus à redução da pena de um sexto a dois terços, deve preencher quatro requisitos: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) não integrar organização criminosa. No presente caso, a despeito de o apelante ser primário e possuir bons antecedentes, entendo que há elementos para afirmar que ele se dedica a atividades criminosas. Isso porque os vários registros da prática de atos infracionais pelo acusado, embora não possam ser aferidos como maus antecedentes para elevar a pena - base ou para caracterizar a reincidência, evidenciam a sua inclinação a práticas delitivas. Destaco que o acusado confessou o seu envolvimento com o tráfico ao afirmar que "fica na boca de fumo de 10:00hs às 18:00hs como atividade" e que "foi apreendido por ato análogo ao art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal; que nessa ocasião o interrogando tentou contra a vida de outra pessoa pois estava cobrando dívida de tráfico de drogas" (sic, fl. 120). Convém destacar que o STJ vem decidindo que o envolvimento do agente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando estiverem relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, pode justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: O envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, é elemento capaz de afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na medida em que revela a sua dedicação em atividades criminosas. Precedente: HC 299.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/812016. (HC 333.749/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017). O registro de atos infracionais é elemento idóneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma. (HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). Portanto, ante o não preenchimento dos requisitos necessários, não é possível aplicar ao apelante a benesse em questão. [...] Com efeito, a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A propósito, precedentes de ambas as Turmas: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro na quantidade, na natureza e na diversidade das drogas apreendidas, no registro de ato infracional análogo tráfico de entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas e integra facção criminosa, a alteração desse entendimento para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idóneo

para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar as regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. 6. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do CP. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para fixar regime inicial semiaberto. (HC n. 423.378/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2017 grifo nosso).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017 grifo nosso).

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque as circunstâncias pessoais impedem a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR WENDEL RAFAEL APARECIDO DORTA ATANAZIO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

O sentenciado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar. Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.
Bragança Paulista, 13 de outubro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA